Aktenzeichen:

7 O 38/14

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[...]
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte [...] und Rechtsanwälte [...]

gegen

1) [...]

2) [...]

3) [...]

4) [...]

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 - 3:
Rechtsanwälte [...]

Prozessbevollmächtigte zu 1 - 4:
Rechtsanwälte [...]

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Voß, den Richter am Landgericht Dr. Tochtermann und den Richter Böttcher am 26.02.2016 auf Grund des Sachstands vom 08.01.2016 ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten jeweils seit dem 21. Oktober 2000

Teilnehmerstationen, denen der Zugriff auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal erteilbar ist,

angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

mit Mitteln zum Empfang von Informationssignalen, wobei die Teilnehmerstationen derart ausgestaltet sind, dass die Zugehörigkeit zu einer Nutzerklasse anhand einer Zugangsberechtigungskarte entnehmbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit derart ausgestaltet ist, dass eine Prüfung bei mit den Informationssignalen empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten anhand der Zugriffsklassenbits erfolgt, wobei die Zugriffsberechtigungsdaten als Bitmuster ausgeführt sind und Zugriffsschwellwertbits für einen Zugriffsschwellwert und Zugriffsklassenbits, die für die Nutzerklassen der mehreren Teilnehmerstationen stehen, enthalten, und dass die Prüfung derart erfolgt, dass die Teilnehmerstation unabhängig von dem Zugriffsschwellwert auf den Telekommunikationskanal zugreift, wenn das der Nutzerklasse der Teilnehmerstation zugeordnete Zugriffsklassenbit 0 ist, und dass ihr in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis des Zugriffschwellwerts mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl der Zugriff auf den Telekommunikationskanal freigegeben wird, wenn das Zugriffsklassenbit 1 ist,

wenn sie gemäß dem Standard 3GPP TS 36.331, Abschnitt 5.3.3.2 zu arbeiten ausgestaltet sind,

wobei sich dies bezüglich der Beklagten zu 4) auf Teilnehmerstationen beschränkt, die von oder im Auftrag der [A.] hergestellt oder vertrieben werden, und

wobei die Beklagte zu 3 die Rechnungslegung für den Zeitraum erst ab dem 15.07.2010 vorzunehmen hat,

(Anspruch 5 von DE 199 10 239 nach der Entscheidung des DPMA)

und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnung) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,

und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkretes Befragen mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagten – die Beklagte zu 3 erst ab dem 15.07.2010 – als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin für die in Ziffer I. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Oktober 2000 bis einschließlich 4. Februar 2011 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,

2. dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. bezeichneten, in der Zeit seit dem 5. Februar 2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 84 % und die Beklagten 16 %, davon 14 %-Punkte als Gesamtschuldner und 2 %-Punkte nach Kopfteilen.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

1. jeweils € 200.000,00 für jede der Beklagten im Hinblick auf Ziff. I (Rechnungslegung),

2. 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages im Hinblick auf Ziffer IV. (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatz- und Entschädigungspflicht in Anspruch.

Die Klägerin, eine Patentverwertungsgesellschaft, ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 199 10 239 B4 (nachfolgend: Klagepatent), das ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal an Teilnehmerstationen eines Telekommunikationsnetzes und eine Teilnehmerstation betrifft, der der Zugriff auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal erteilbar ist. Die Erteilung des am 8. März 1999 angemeldeten Patents wurde am 5. Januar 2011 veröffentlicht. Offenlegungstag ist der 21.09.2000. Das Klagepatent ist Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Das Deutschen Patent- und Markenamt hat mit nicht rechtskräftigem Beschluss vom 6. März 2013 den ursprünglich erteilten Klagepatentanspruch 6 dergestalt abgeändert, dass dieser – in der Nomenklatur der Klägerin und des Deutschen Patent- und Markenamtes nunmehr als Anspruch 5 bezeichnete – Anspruch nunmehr den folgenden Wortlaut hat:

5. Teilnehmerstation, der der Zugriff auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal erteilbar ist,

   mit Mitteln zum Empfang von Informationssignalen,

   wobei die Teilnehmerstation derart ausgestaltet ist, dass die Zugehörigkeit zu einer Nutzerklasse anhand einer Zugangsberechtigungskarte entnehmbar ist,

   dadurch gekennzeichnet, dass

   eine Auswerteeinheit derart ausgestaltet ist, dass eine Prüfung bei mit den Informationssignalen empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten anhand der Zugriffsklassenbits erfolgt,

   wobei die Zugriffsberechtigungsdaten als Bitmuster ausgeführt sind und Zugriffsschwellwertbits für einen Zugriffsschwellwert

   und Zugriffsklassenbits, die für die Nutzerklassen der mehreren Teilnehmerstationen stehen, enthalten,

   und dass die Prüfung derart erfolgt,

   dass die Teilnehmerstation unabhängig vom Zugriffsschwellwert auf den Telekommunikationskanal zugreift, wenn das der Nutzerklasse der Teilnehmerstation zugeordnete Zugriffsklassenbit 0 ist,

   und dass ihr in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis des Zugriffsschwellwerts mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl der Zugriff auf den Telekommunikationskanal freigegeben wird, wenn das Zugriffsklassenbit 1 ist.

Die Klägerin legt diesen Anspruch in der von Deutschen Patent- und Markenamt aufrechterhaltenen Fassung ihrer Klage zugrunde.

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen, die als Anlage K 7 zu den Akten gereicht wurde.

Die Beklagten zu 2 und zu 3 sind (mittelbare) Tochtergesellschaften der Beklagten zu 1, eines [...]ischen Elektronikkonzerns, der u.a. Mobiltelefone herstellt und weltweit vertreibt. Die Beklagte Ziff.1 betreibt unter der domain www.[...].com einen weltweiten Internetauftritt, in dem unter anderem Mobilfunktelefone, sogenannte Smartphones, beworben werden. Teil dieses Internetauftritts ist die für Deutschland einschlägige Unterseite www.[...].com/de.

Die Beklagte zu 2, die [...]ische Tochtergesellschaft, betreibt die Internetseite www.[...]-partners.com.

Die Beklagte zu 4 ist der präferierte Distributionspartner der Beklagten zu 1 in Deutschland und bietet deren Mobiltelefone u.a. über einen Online-Shop an.

Die Klage richtet sich gegen den Vertrieb LTE-fähiger Mobilstationen („angegriffene Ausführungsformen").

LTE (Long-Term-Evolution) (im Folgenden „(LTE-)Standard") ist eine Weiterentwicklung des UMTS-Standards (Universal Mobile Telecommunications System) und wird oft als Mobilfunkstandard der vierten Generation („4G") bezeichnet. LTE setzt auf den UMTS-Standard auf. Entsprechend gibt es neben dem UMTS-Zugangsnetzwerk UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) ein „Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network" (E-UTRAN).

Die Funktionsweise der beiden Mobilfunkstandards ist in einzelnen Dokumenten des European Telecommunications Standards Institute (ETSI) niedergelegt.

In dem Standard ETSI TS 136 331 V8.11.0 Release 8 ist geregelt, wie LTE-fähige Mobilstationen auf das E-UTRAN zugreifen. Auszüge aus diesem Standarddokument liegen als Anlage K 58 vor. Eine neuere Fassung des Standards, nämlich die Dokumente TS 136 331 V8.12.0, V9.5.0 und V10.0.0 Release 10, wurde im Januar 2011 veröffentlicht und von den Parteien mit den Anlagen [B] 1a, 1b und 1 c sowie K 68 bis K 70 ebenfalls in Auszügen vorgelegt.

Für die Zuteilung von Nutzerklassen (Access Class) an Mobilstationen bezieht sich LTE auf den Standard TS 22.011, Abschnitt 4.2. Dort sind die Access Classes 11 bis 15 vorgesehen, die besonders bevorrechtigten Nutzern wie z.B. Notdiensten zugeteilt sind.

Das Mobilfunknetzwerk sendet die Zugriffsberechtigungen für den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal RACH (*Random Access Channel*) beim LTE-Standard über den Broadcast-Control-Channel. Dabei sendet es in einer System-Information-Block-Type-2- (SIB 2)-Nachricht als Teil des dortigen Informationselements AC-Barring-Info, dort des Elements AC-BarringConfig, zwei für die Ermittlung der Zugriffsberechtigung erforderliche Parameter an die Mobilstationen, nämlich den Parameter ac-BarringForSpecial AC mit fünf Bits, von denen jedes für eine der Access Classes 11 bis 15 steht, und den Parameter ac-BarringFactor. Der ac-BarringFactor gibt einen sog. Persistenzwert an, wobei die Persistenzwerte p00 für 0, p05 für 0,05, p10 für 0,1, ..., p95 für 0,95 stehen, so dass der ac-BarringFactor Werte im Bereich zwischen 0 und 1 vorgeben kann.

Für den Zugriff auf den wahlfreien Zugriffskanal RACH sieht das Standard-Dokument ETSI TS 136 331 V8.11.0 Release 8 in Abschnitt 5.3.3.2 das folgende ausschnittsweise eingeblendete Verfahren für den Fall des Aufbau einer Verbindung durch eine Mobilstation („*mobile originating call*") vor, wobei RRC für Radio Resource Control steht:

1> else if the UE is establishing the RRC connection for mobile originating calls:

2> if timer T302 or T303 is running:

3> consider access to the cell as barred;

2> else if *SystemInformationBlockType2* includes the *ac-BarringInfo* and the *ac-BarringForMO-Data* is present:

3> if the UE has one or more Access Classes, as stored on the USIM, with a value in the range 11..15, which is valid for the UE to use according to TS 22.011 [10] and TS 23.122 [11], and

3> for at least one of these Access Classes the corresponding bit in the *ac-BarringForSpecialAC* contained in *ac-BarringForMO-Data* is set to *zero*:

4> consider access to the cell as not barred;

3> else:

4> draw a random number '*rand*' uniformly distributed in the range: $0 \leq rand < 1$;

4> if '*rand*' is lower than the value indicated by *ac-BarringFactor* included in *ac-BarringForMO-Data*:

5> consider access to the cell as not barred;

4> else:

5> consider access to the cell as barred;

2> else:

3> consider access to the cell as not barred;

Demnach prüft die Mobilstation zunächst, ob einer der beiden Timer T302 oder T303 läuft. Ist dies nicht der Fall, überprüft sie, ob die vom Netzwerk empfangene Information SIB 2 die ac-Barring-Info enthält, die u.a. die ac-BarringForSpecialAC-Information und den ac-BarringFactor umfasst. Im nächsten Schritt liest sie ihre Nutzerklasse aus ihrer SIM-Karte aus und prüft, ob sich auf ihrer SIM-Karte mindestens eine der Access-Classes 11 bis 15 befindet. Wenn eine solche Nutzerklasse vorhanden ist und für zumindest eine dieser Nutzerklassen das entsprechende Bit in der ac-BarringForSpecialAC auf 0 gesetzt ist, erhält die Mobilstation unmittelbaren Zugriff auf den RACH. Andernfalls generiert die Mobilstation einen Zufallswert zwischen 0 (einschließlich) und 1 (ausschließlich) und vergleicht diesen mit dem ac-BarringFactor. Ist der Zufallswert geringer als der ac-BarringFactor, erhält sie Zugriff, andernfalls nicht.

Neuere Versionen des LTE-Standards, nämlich die Standarddokumente ETSI TS 136 331 V8.12.0 (11-01) (Anlage [B] 1a, Abschnitt 6.3.1 auf Seite 105), ETSI TS 136 331 V9.5.0 (20011-01) (vgl. Anlage [B] 1b, dort Abschnitt 6.3.1 auf Seite 127) und ETSI TS 136 331 V10.0.0 (2011-1) (vgl. Anlage [B] 1c, dort Abschnitt 6.3.1 auf Seite 141) sehen eine Einschränkung für den ac-BarringFactor vor. Insoweit ist bei der Beschreibung des ac-BarringFactor der folgende Satz ergänzt worden:

„Values other than ‚p00' can only be set if all bits of the corresponding acBarringForSpecial-AC are set to 0"

Ein Wert p00 bedeutet, dass kein Zugriff gewährt wird, da jede ermittelte Zufallszahl aus dem Bereich zwischen 0 und 1 größer oder gleich 0 ist und damit die Mobilstation den Vergleich mit dem ac-BarringFactor stets verliert.

Die Klägerin ist der Auffassung, die durch die Beklagten hergestellten und vertriebenen LTE-fähigen Mobilfunkgeräte seien dazu geeignet und bestimmt, die durch Anspruch 5 des Klagepatents gelehrte Erfindung zu benutzen. Mangels Berechtigung verletzten die Beklagten Anspruch

5 des Klagepatents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, weil die standardgemäß arbeitenden Mobilfunkgeräte sämtliche Merkmale des Anspruchs wortsinngemäß verwirklichten. Die oben angesprochene Änderung hinsichtlich des ac-BarringFactor im Januar 2011 sei nicht zwingend und führe im Übrigen nicht aus einer Patentverletzung hinaus.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts sei jedenfalls mit Blick auf die Schutzfähigkeit des mit der hiesigen Klage geltend gemachten Anspruchs 5 in der vom Deutschen Patent- und Markenamt aufrechterhaltenen Fassung zutreffend. Die Ausführungen des Bundesgerichtshof in dem Nichtigkeitsverfahren X ZR 35/11 betreffend das Patent EP 1 186 189 seien nicht auf das hiesige Klagepatent übertragbar, jedenfalls seien sie unrichtig.

Die Klägerin hat zuletzt – nach teilweiser Rücknahme der Klage im Hinblick auf die Ansprüche auf Unterlassung, auf Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen und auf Vernichtung sowie teilweiser Rücknahme des Rechnungsanspruchs im Hinblick auf die Gestehungskosten und den Gewinn – beantragt:

> Ziffer I und II wie erkannt, jedoch ohne die zeitliche Beschränkung bei der Beklagten zu 3 auf den Zeitraum ab dem 15.07.2010

Die Beklagten beantragen,

> die Klage abzuweisen,
>
> hilfsweise den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zu der Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen 19 W (pat.) 69/13 über die Beschwerde gegen den Beschluss der Patenterteilung vom 12.07.2013 (Az.: 199 10 239.2-31) auszusetzen.

Die Beklagten sind der Auffassung, dass die Einführung des oben zitierten Zusatzes in die Beschreibung des ac-BarringFactor aus dem Standard im Januar 2011 dazu führe, dass sich die vermeintliche Verwirklichung des Merkmals 7 nicht mehr aus zwingenden Vorgaben des Standards ergebe. Es sei nicht sinnvoll, die Mobilstationen so auszugestalten, dass sie in Abhängigkeit vom Inhalt des entsprechenden Bits in der ac-BarringForSpecialAC einen Abgleich zwischen einem Zufallswert und dem ac-BarringFactor durchführe, obwohl dieser Abgleich stets zu einer Zugriffsverweigerung führe und daher unnötig Akku-Leistung verbrauche. Die Beklagten behaupten ferner, sie würden derzeit nur noch solche LTE-fähigen Endgeräte nach Deutschland einführen, die über LTE-Basisband-Chipsets der Firma [X.] mit den Typenbezeichnungen „[...]", „[...]", „[...]", „[...]", „[...]" und „[...]" verfügten. Diese Chipsätze verfügten über eine abgeänderte Steuerungssoftware, die bewirke, dass die von der Klägerin zur Begründung der Patentverletzung herangezogene RRC-Connection-Request-Establishment-Prozedur in anderer Weise durchgeführt werde. Die Änderungen seien am 19.09.2014 bei der Chipherstellerin beantragt und dann in der internen Firmware der Beklagten bis Ende November 2014 umgesetzt worden.

Unabhängig davon seien die Beklagte zu 2 und 3 nicht passivlegitimiert.

Jedenfalls werde das Klagepatent im Einspruchsverfahren widerrufen werden. Die Entscheidung der Patentabteilung sei auf der Grundlage der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren X ZR 35/11 betreffend das Patent EP 1 186 189 unzutreffend.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist im Umfang der zuletzt gestellten Anträge begründet. Die teilweise Klagerücknahme durch die Klägerin ist wirksam (dazu I.). Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen Anspruch 5 des Klagepatents (dazu II.) wortsinngemäß (dazu III.). Der Klägerin stehen daher die zugesprochenen Ansprüche zu (dazu IV.). Eine Aussetzung des Rechtsstreit war nicht angezeigt (dazu V.).

I.

Die mit Klägerschriftsatz vom 08.01.2016 erklärte teilweise Klagerücknahme ist wirksam. Einer Einwilligung durch die Beklagten bedurfte es nicht. Eine Klagerücknahme ist bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache ohne Einwilligung möglich (§ 269 Abs. 1 ZPO). Ein solches Verfahrensstadium war zum Zeitpunkt der teilweisen Klagerücknahme vom 08.01.2016 vorliegend noch nicht erreicht.

1. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 11.12.2015 wurde das Stadium eines Beginns der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache nicht erreicht. Zu den ursprünglichen Klageanträgen wurde nicht verhandelt. Die Klägerin hat von einer Antragsstellung bewusst abgesehen. Es wurden auch keine Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorgebracht, die unabhängig von der Antragstellung den Beginn der mündlichen Verhandlung begründen können.

2. Auch im schriftlichen Verfahren war aufgrund der besonderen Umstände vor der teilweisen Klagerücknahme mit Schriftsatz vom 08.01.2016 noch kein dem Beginn der mündlichen Verhandlung entsprechendes Verfahrensstadium erreicht.

   a) Im schriftlichen Verfahren markiert zwar der Eingang der letzten Zustimmungserklärung zum schriftlichen Verfahren den Beginn der mündlichen Verhandlung (vgl. *Greger* in Zöller, ZPO, 31. Aufl., § 269 Rn. 13 aE, § 128 Rn. 13; ferner – im Kontext zu § 274 Abs. 3 ZPO a.F. – BGH, NJW 1970, 198). Dies wäre vorliegend der 11.12.2015, da beide Parteien ihre Zustimmung noch im Termin erklärt haben. Nach Auffassung der Kammer setzt dies jedoch voraus, dass die Parteien, jedenfalls die Klägerin, dem Gericht im Zeitpunkt der Zustimmung zum schriftlichen Verfahren die schriftsätzlich angekündigten Anträge auch zur Entscheidung stellen möchten. Dies wird regelmäßig der Fall sein, so dass regelmäßig in der Zustimmung zum schriftlichen Verfahren zugleich die Erklärung liegt, mit den angekündigten Anträgen im schriftlichen Verfahren verhandeln zu wollen. Regelmäßig wird daher die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren die schriftsätzliche Stellung der bisher lediglich angekündigten Anträge und damit das Pendant zur Antragstellung in der mündlichen Verhandlung sein. Eine Abweichung von diesem Grundsatz ist nach Auffassung der Kammer aber dann geboten, wenn der Kläger mit den schriftsätzlich angekündigten Anträgen nicht im schriftlichen Verfahren verhandeln möchte, sondern ankündigt, andere Anträge stellen zu wollen, denn in diesem Fall kann in der Zustimmungserklärung nicht die Stellung der zuvor lediglich schriftsätzlich angekündigten Anträge, an denen der Kläger aber erkennbar nicht mehr festhalten möchte, gesehen werden. Ohne eine Antragstellung oder vergleichbare Handlungen kann das schriftliche Verfahren im Zeitpunkt der Zustimmungserklärungen noch kein Stadium erreicht haben, das dem des Beginns der mündlichen Verhandlung entspricht. In diesem Sinne ist nach Auffassung der Kammer auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10.11.1969 (NJW 1970, 198) zu verstehen. Der Bundesgerichtshof führt zunächst aus, dass im schriftlichen Verfahren die mündliche Verhandlung dadurch ersetzt werde, dass die Parteien dem Ge-

richt den Streitstoff und insbesondere ihre Anträge schriftsätzlich unterbreiten. Auch der Bundesgerichtshof sieht es mithin als erforderlich an, dass die Anträge schriftsätzlich gestellt werden, was bei lediglich angekündigten Anträgen, die nicht mehr aufrechterhalten werden sollen, nach Auffassung der Kammer gerade nicht der Fall ist. Soweit der Bundesgerichtshof es im weiteren Fortgang seines Urteils als naheliegend angesehen hat, für den Beginn der mündlichen Verhandlung auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die letzte Erklärung des Einverständnisses mit dem schriftlichen Verfahren abgegeben wird, gilt dies unter der oben dargestellten Prämisse, dass die (angekündigten) Anträge auch schriftsätzlich in dem oben dargelegten Sinne gestellt sind, was nach Auffassung der Kammer dann nicht der Fall ist, wenn die Klägerseite bereits erklärt hat, die angekündigten Anträge nicht stellen zu wollen, weil sie sie abändern möchte. Weiter führt der Bundesgerichtshof aus, dass die Beklagtenseite im schriftsätzlichen Verfahren grundsätzlich dann nicht mit prozesshindernden Einreden, zumindest nicht mit der Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des Gerichts ausgeschlossen werden kann, wenn sie sich diese im Antrag auf das schriftliche Verfahren ausdrücklich vorbehält und sie rechtzeitig nachbringt. Denn in diesem Fall werde erkennbar, dass die Beklagtenseite ihre Ausführungen zur Hauptsache nur hilfsweise und nur für den Fall berücksichtigt haben will, dass sie nicht noch die vorbehaltene Einrede der örtlichen Unzuständigkeit rechtzeitig erhebt. Dem lässt sich zweierlei entnehmen. Zum einen bedeutet die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren nicht zwingend ein dem Beginn der mündlichen Verhandlung gleichgestelltes Verhandeln zur Sache, wenn die Beklagtenseite sich vorbehält, nicht unbedingt zur Sache verhandeln zu wollen, sondern zunächst eine prozessuale Einrede erheben und lediglich hilfsweise zur Sache verhandeln zu wollen. Zum anderen stellt der Bundesgerichtshof lediglich einen Grundsatz auf. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Auffassung, dass die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren nicht zwangsläufig den Beginn der in verschiedenen Zusammenhängen eine Zäsur bildenden mündlichen Verhandlung markiert, nicht auch zugunsten der Klägerseite gelten sollte.

b) Bei Anlegung dieser Maßstäbe war im Zeitpunkt der teilweisen Klagerücknahme mit Schriftsatz vom 08.01.2016 der Zeitpunkt, der dem Beginn der mündlichen Verhandlung entspricht und ab dem eine teilweise Klagerücknahme ohne Einwilligung der Beklagtenseite nicht mehr möglich ist, noch nicht erreicht.

Die Klägerin hatte im Termin am 11.12.2015 ausdrücklich erklärt, an den schriftsätzlich angekündigten Anträgen nicht festhalten zu wollen. Hintergrund des Vorschlags für den Übergang in das schriftliche Verfahren mit der relativ kurzen Zeitspanne bis zum Schlusstermin war u.a. gerade die Ankündigung der Klägerin, ihre Anträge ändern zu wollen. Die Klägerin hat von einer Stellung abgeänderter Anträge gerade mit Blick darauf, dass sie das auch im schriftlichen Verfahren noch tun könne, abgesehen. Allen Beteiligten war klar, dass neue Anträge folgen werden. Vor diesem Hintergrund ist unschädlich, dass sich die Klägerin die Änderung ihrer Anträge nicht auch explizit in der Zustimmungserklärung vorbehalten hat. Zu fordern, dass die Klägerin eine Zustimmungserklärung etwa mit dem ausdrücklichen Wortlaut, dem schriftlichen Verfahren nur mit der Maßgabe zuzustimmen, dass sie sich die Änderung der angekündigten Anträge vorbehält und neue Anträge im schriftlichen Verfahren einreicht, abgeben müsste, wäre vorliegend aufgrund der Gesamtumstände bloße Förmelei gewesen.

Auch andere Verfahrenshandlungen, die mit einer Antragstellung vergleichbar sind, waren vorliegend nicht gegeben. Jedenfalls stünden sie der angekündigten Antragsänderung im schriftlichen Verfahren nicht entgegen.

c) Die Richtigkeit dieses Ergebnisses wird durch die folgende Vergleichsbetrachtung weiter gestützt. Die Kammer hatte am 11.12.2015 die Möglichkeit, die mündliche Verhandlung zu vertagen oder in das schriftliche Verfahren überzugehen. Hätte sie die Vertagung gewählt, hätte die Klägerin, die mit den angekündigten Anträgen nicht verhandeln wollte, ohne die Einwilligung der Beklagten die Anträge teilweise zurücknehmen können. Dass die Kammer das schriftliche Verfahren vorgeschlagen hat, hatte den Vorteil, den Prozessbeteiligten den Aufwand für eine weitere mündliche Verhandlung zu ersparen. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht einsichtig, weshalb die Klägerin im Fall einer Vertagung ihre angekündigten, aber nicht gestellten Anträge ohne Einwilligung der Beklagten zurücknehmen könnte, im Fall des schriftlichen Verfahrens jedoch nicht, obwohl sie keinen Zweifel daran gelassen hat, mit den schriftsätzlich angekündigten Anträgen nicht verhandeln zu wollen.

3. Den Beklagten wurde hinsichtlich der teilweisen Klagerücknahme auch rechtliches Gehör gewährt. Beide Beklagtenvertreter haben den Klägerschriftsatz vom 08.01.2016 mit der teilweisen Klagerücknahme im Wege der Parteizustellung erhalten. Dies ergibt sich einerseits aus dem von der Klägerin mit Schriftsatz vom 25.02.2016 vorgelegten Empfangsbekenntnis, andererseits aus dem Beklagtenschriftsatz vom 20.01.2016, in dem die dortigen Unterzeichner den Erhalt des Klägerschriftsatzes vom 08.01.2016 ausdrücklich bestätigen. Mit Verfügungen vom 26.01.2016 (AS 457, 458) wurde der ursprüngliche Verkündungstermin verlegt und den Beklagten Gelegenheit gegeben, sich zu der teilweisen Klagerücknahme zu erklären. Die Beklagten hatten damit ausreichend Gelegenheit, sich zu der teilweisen Klagerücknahme einzulassen. Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer davon ab, dem Beklagtenantrag auf nochmalige Verlegung des Verkündungstermins (AS 488) zu entsprechen. Soweit in der Begründung des Verlegungsantrags darauf abgehoben wird, dass die teilweise Klagerücknahme noch nicht zugestellt worden sei, bezieht sich dies offenbar auf eine fehlende gerichtliche Zustellung. Für die prozessuale Erklärung der teilweisen Klagerücknahme und die Gewährung rechtlichen Gehörs kommt es indes nicht auf eine gerichtliche Zustellung an.

II.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal an Teilnehmerstationen eines Telekommunikationsnetzes und Teilnehmerstationen, denen ein solcher Zugriff erteilbar ist.

1. Nach der Beschreibungseinleitung des Klagepatents waren Verfahren zur Zugriffskontrolle auf einen Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes für mindestens eine Teilnehmerstation im Stand der Technik bekannt, wobei Informationssignale an diese übertragen wurden. Das Klagepatent würdigt insbesondere die Patentschrift US 4,707,832 als Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten, bei dem den Teilnehmerstationen Zugriff auf einen Telekommunikationskanal in Abhängigkeit eines Vergleichs eines Zugriffsschwellwerts mit einer Zufallszahl gewährt wird. Als Gegenstand der Druckschrift WO96/08939A1 schildert es ein Verfahren als bekannt, bei dem den Teilnehmerstationen der Zugriff in Abhängigkeit von Zugriffsklasseninformationen erteilt wird. Ferner würdigt es als Stand der Technik den GSM Standard 04.60, Version 6.2.0 und 6.1.0, den Standard TIA/EIA/IS 95-A und die Druckschrift WO 98/37668A1. Danach setzt das Klagepatent Verfahren als bekannt voraus,

bei denen der Zugriff vom Vergleich eines Zugriffsschwellwerts mit einer Zufallszahl abhängt, bei denen unterschiedliche Zugriffsschwellwerte für unterschiedliche Nutzerklassen vorgesehen sind oder bei denen der einzelnen Teilnehmerstation für eine beschränkte Zeitdauer der gesamte Kanal zur Übertragung zur Verfügung gestellt wird.

2. Demgegenüber schlägt das Klagepatent ein Verfahren vor, bei dem mit den Informationssignalen Zugriffsberechtigungsdaten einschließlich eines – vorteilhafterweise in Abhängigkeit von dem Nachrichtenverkehrsaufkommen höher oder niedriger gewählten – Zugriffsschwellwerts übertragen werden und der Zugriffsschwellwert mit einer Zufallszahl oder Pseudozufallszahl verglichen wird, wobei das Zugriffsrecht auf den Telekommunikationskanal grundsätzlich von diesem Schwellwertvergleich abhängt. Ziel dieser Maßnahme ist nach der Beschreibung des Klagepatents eine zufällige Verteilung der Zugangsberechtigung zu dem Telekommunikationskanal. Daneben existieren nach dem patentgemäßen Verfahren Teilnehmerstationen, die einer Nutzerklasse angehören, die unabhängig von dem Schwellwertvergleich auf den Telekommunikationskanal zugreifen darf. Als Anwendungsbeispiel für einen solchermaßen priorisierten Zugriff nennt das Klagepatent Notdienste wie Polizei oder Feuerwehr. Ob einer Nutzerklasse unabhängig vom Schwellwertvergleich Zugriffsberechtigung gewährt wird, entscheidet sich nach der Lehre des Klagepatents anhand des ihr „zugeordneten Zugriffsklassenbits".

3. Hiervon ausgehend stellt das Klagepatent neben dem erfindungsgemäßen Verfahren eine Teilnehmerstation unter Schutz, die durch die nachfolgend aufgeführten Merkmale gekennzeichnet ist:

   1. Teilnehmerstation (5,10,15, 20), der der Zugriff auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal erteilbar ist,
   2. mit Mitteln (65) zum Empfang von Informationssignalen,
   3. wobei die Teilnehmerstation (5,10,15, 20) derart ausgestaltet ist, dass die Zugehörigkeit zu einer Nutzerklasse (35, 40) anhand einer Zugangsberechtigungskarte (75) entnehmbar ist,
   4. dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit (60) derart ausgestaltet ist, dass eine Prüfung bei mit den Informationssignalen empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) anhand der Zugriffsklassenbits (Z3, Z2, Z1, Z10) erfolgt,
   5. wobei die Zugriffsberechtigungsdaten (35, 50, 55),
      - als Bitmuster ausgeführt sind und
      - Zugriffsschwellenwertbits (S3, S2, S1, S0) für einen Zugriffsschwellwert (S) und
      - Zugriffsklassenbits (Z3, Z2, Z1, Z0), die für die Nutzerklassen (35, 40) der mehreren Teilnehmerstationen (5,10,15, 20) stehen,

      enthalten;
   6. die Prüfung derart erfolgt, dass die Teilnehmerstation (5,10,15, 20) unabhängig von dem Zugriffsschwellenwert (S) auf den Telekommunikationskanal zugreift, wenn das der Nutzerklasse der Teilnehmerstation (5,10,15, 20) zugeordnete Zugriffsklassenbit (Z3, Z2, Z1, Z0) 0 ist,
   7. und dass ihr in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis des Zugriffsschwellenwerts (S) mit einer Zufallszahl oder Pseudo-Zufallszahl (R) der Zugriff auf den Telekommunikationskanal freigegeben wird, wenn das Zugriffsklassenbit (Z3, Z2, Z1, Z0) 1 ist.

III.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 5 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies steht aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung der Parteien für sämtliche Anspruchsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals 7 außer Streit. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch Merkmal 7. Für angegriffene Ausführungsformen vor der Änderung des Standards im Januar 2011 ist dies zwischen den Parteien unstreitig, gilt aber auch für solche nach der Standardänderung vor der von den Beklagten behaupteten Änderung der Steuersoftware der Chips.

1. Merkmal 7 sieht vor, dass die Prüfung durch die Teilnehmerstation derart erfolgt, dass ihr in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis des Zugriffsschwellenwerts (S) mit einer Zufallszahl oder Pseudo-Zufallszahl (R) der Zugriff auf den Telekommunikationskanal freigegeben wird, wenn das Zugriffsklassenbit (Z3, Z2, Z1, Z0) 1 ist.

   Die Klägerin hat das der jeweiligen Nutzerklasse 11 bis 15 zugeordnete Bit, welches nach dem Standard in der als Teil der AC-BarringConfig von dem Netzwerk an die Teilnehmerstationen gesendeten Information ac-BarringForSpecialAC enthalten ist und bei dem es sich pro Nutzerklasse um ein einziges „physikalisches" Bit im Sinne der kleinsten digitalen Datenmenge handelt, als anspruchgemäßes Zugriffsklassenbit angesehen. Als patentgemäßen Zugriffsschwellenwert hat die Klägerin den ebenfalls in der AC-BarringConfig enthaltenen ac-BarringFactor des Standards identifiziert. Sodann hat die Klägerin für das Beispiel, dass eine Mobilstation eine Verbindung aufbauen möchte, anhand des Abschnitts 5.3.3.2 des LTE-Standards erläutert, dass in dem Fall, dass das entsprechende Bit in der ac-BarringForSpecialAC auf 1 gesetzt wird, von der Mobilstation ein Zufallswert generiert und mit dem Wert des ac-Barringsfactor abgeglichen wird. Ist der ermittelte Zufallswert kleiner als der ac-Barringfactor, werde ein Zugriff auf den RACH zugelassen, andernfalls nicht. Aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung stellen die Beklagten weder den von der Klägerin dargestellten Sinngehalt des Merkmals 7 noch die Richtigkeit der Darstellung der im Standard niedergelegten Prozedur des Verbindungsaufbaus durch eine Mobilstation in Abrede. Auch der klägerischen Behauptung, dass die Schritte jeweils identisch für die Etablierung einer RRC-Verbindung für Signalisierungsnachrichten der Teilnehmerstation und – in der Version 10.0.0 – für ein von der Teilnehmerstation ausgehendes „CS fallback" seien, sind die Beklagten – ohne das es hierauf für die Entscheidung ankäme – nicht entgegengetreten.

2. Vor diesem Hintergrund steht die wortsinngemäße Verwirklichung des Anspruchs 5 des Klagepatents fest.

   a) Für den Zeitraum vor der Änderung beim ac-BarringFactor im LTE-Standard im Januar 2011 haben die Beklagten nicht hinreichend in Abrede in gestellt, dass ihre Mobilstationen nach dem LTE-Standard ausgebildet und damit patentverletztend sind. Sie haben insbesondere nicht behauptet, dass die angegriffenen Ausführungsformen so ausgestaltet wären, dass sie nicht geeignet sind, die von der Klägerin in Bezug genommene Prozedur zu durchlaufen.

   b) Soweit die Beklagten sich darauf berufen, dass die Vorgaben des Standards nach der Änderung der Vorgaben bzgl. des ac-BarringFactors im Januar 2011 nicht mehr zwingend seien, so dass sich die Klägerin für die Darlegung des Verletzungsvorwurfs nicht auf die Darlegung des Standards zurückziehen könne, verfängt dies nicht. Die Änderungen bzgl. des ac-BarringFactors ab dem Januar 2011 nehmen der Klägerin nicht die

Möglichkeit, sich für die Darlegung der Verwirklichung des Merkmals 7 auf den Standard zu berufen.

aa) Ab dem Januar 2011 wurde der Standard dahingehend geändert, dass andere Werte als p00 für den ac-BarringFaktor nur gesetzt werden können, wenn die Bits der AC-BarringInfo alle auf 0 stehen, also wenn alle Nutzerklassen einen barrierefreien Zugriff haben. Aus dieser Regelung folgt im Umkehrschluss, dass der Wert p00 zu setzen ist, wenn nicht alle Nutzerklassen 11 bis 15 bevorrechtigt sind. Gibt es also nur eine nicht bevorrechtige Nutzerklasse, ist der ac-Barringfactor auf den Wert p00 zu setzen. Ein Wert p00 hat zur Folge, dass in diesem Fall der Zugriff blockiert ist, weil die von der Mobilstation generierte Zufallszahl stets größer oder gleich 0 ist und damit die Mobilstation den Vergleich mit dem ac-BarringFactor stets verliert.

bb) Es kann offen bleiben, ob die neue Vorgabe zwingend ist und auch für ältere LTE-Netzwerke gilt oder Abweichungsmöglichkeiten bestehen, denn die Vorgabe richtet sich allein an das Netzwerk. Sie lässt die übrigen Vorgaben des Standards für die Mobilstationen unberührt. Diese müssen nach dem Standard nach wie vor so ausgestaltet sein, dass sie die im Tatbestand dargestellte Prozedur wie vorgesehen durchführen können, auch wenn die Prozedur im Vergleich zu ihrer früheren Bedeutung sinnentleert sein mag. Auch nach der Änderung beim ac-BaringFactor ist im Standard zwingend vorgeschrieben, dass die Mobilstationen so eingerichtet sein müssen, dass sie die im Tatbestand dargestellte Prozedur für die Fälle Mobil-originating-calls, Mobile-originating-signalling und Mobile-originating-CS-fallback durchführen können (vgl. Anlage K 68, S. 32 ff., Anlage K 69, S. 35 f., Anlage K 70, S. 36 f.). Der (weiterhin) zwingende Charakter der diesbezüglichen Vorgaben ergibt sich aus der Verwendung des Worts „shall". Die Klägerin hat dargelegt, dass in der Terminologie des Standards „shall" eine zwingende Vorgabe bezeichnet. Dem sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Solange die Mobilstationen weiter geeignet sind, die vorgesehene Prozedur zu durchlaufen, kommt es schon nicht darauf an, ob das Netzwerk ihnen die Prozedur auch abverlangt. Für die Patentverletzung genügt nämlich, dass die Vorrichtung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht und geeignet ist, die patentgemäßen Wirkungen herbeizuführen (BGH, GRUR 2006, 399 ff. - Rangierkatze). Abgesehen davon führt der Umstand, dass das Netzwerk immer einen Barringfaktor p00 sendet, wenn nicht alle Nutzerklassen bevorrechtigt sind, weiterhin dazu, dass in Abhängigkeit von dem Zugriffsklassenbit festgelegt wird, ob die Mobilstation Zugriff auf den RACH unabhängig vom Zugriffsschwellenwert erhält oder der patentgemäße Abgleich zwischen dem BarringFactor und dem Zufallswert durchgeführt wird. Eine für mindestens eine Nutzerklasse bevorrechtigte Mobilstation erhält demnach auch weiterhin Zugriff unabhängig vom Zugriffsschwellenwert. Für Mobilstationen mit keiner bevorrechtigten Nutzerklasse, wird nach wie vor der patentgemäße Zugriffsschwellenvergleich durchgeführt, wobei – da nicht alle Nutzerklassen bevorrechtigt sind – ein ac-BarringFactor von 0 vorgegeben wird, so dass der Zugriffswertvergleich zwingend zur Zugriffsverweigerung führt. Dass das Ergebnis dieses Abgleichs aufgrund des Inputs des Netzwerks von vornherein feststeht, ändert an der Durchführung der Prozedur mit dem Zugriffsschwellenvergleichstest und der Eignung der nach dem Standard ausgebildeten Mobilstation, die Prozedur wie vorgesehen – ggf. auch mit anderen ac-BaringFactors – durchzuführen, nichts. Ob es unter der Bedingung, dass der ac-BarringFactor wie nach den

Änderungen festgelegt wird, sinnvoll ist, die Prozedur durchzuführen, ist für die Verwirklichung des patentgemäßen Lehre, wie sie ihren Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat, nicht erheblich.

cc) Es liegt damit die Konstellation vor, dass nach dem LTE-Standard ausgebildete Mobilstationen, in denen die vom Standard vorgesehene Prozedur wie vorgesehen implementiert ist, auch nach der Änderung des Standards vom Januar 2011 von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, dass es aber möglich ist, in diesem Punkt vom Standard und der Lehre des Klagepatents abzuweichen, ohne dass dies dazu führen würde, dass die Mobilstation technisch nicht mehr in der Lage wäre, in einem LTE-Netzwerk, das die Änderungen beim ac-BarringFactor umgesetzt hat, zu funktionieren.

Der Umstand, dass es nicht sinnvoll erscheinen mag, eine Fähigkeit der Mobilstationen vorzuhalten, die nicht mehr benötigt wird, und dass ein Mobiltelefon auch dann funktioniert, wenn es von den zwingenden Vorgaben des Standards abweicht, schließt es indes nicht aus, dass die Klägerin sich zur Darlegung des Verletzungstatbestands im ersten Zugriff weiterhin auf den Standard berufen kann. Ob in einer solchen Konstellationen eine Vermutung besteht, dass unstreitig standardkompatible Mobilstationen auch die zwingend vorgeschriebenen, aber technisch zur Erreichung der Kompatibilität nicht erforderlichen Vorgaben des Standards wie vorgesehen implementieren, kann dahinstehen. Jedenfalls wird sich die Beklagtenseite nicht mit dem bloßen Hinweis begnügen können, eine Mobilstation sei auch dann standardkompatibel, wenn sie von den zwingend vorgeschriebenen Vorgaben des Standards abweiche. Vielmehr müsste die Beklagtenseite zumindest konkret bestreiten, dass die angegriffenen Ausführungsformen zwingende Vorgaben des Standards, zu denen es eine technische Alternative gibt, nicht wie vorgesehen umsetzen. Ein solches Bestreiten ist vorliegend nicht gegeben. Die Beklagten haben lediglich für verschiedene Chips dargelegt, dass die Steuersoftware zu bestimmten Stichtagen im November 2014 so abgeändert worden sei, dass sie einen anderen Programmablauf haben. Zu den Verhältnissen vor diesen Stichtagen haben sich die Beklagten nicht verhalten, so dass unstreitig ist, dass die Mobiltelefone jedenfalls vor diesen Stichtagen so eingerichtet waren, dass sie nach dem im LTE-Standard vorgesehenen Programmablauf gesteuert wurden.

c) Ob auch die Mobiltelefone der Beklagten mit den abgeänderten Chips das Merkmal 7 noch verwirklichen, bedarf keiner Entscheidung, denn die Klägerin hat nicht, etwa durch eine entsprechende Antragstellung, klargestellt, dass sie auch eine Entscheidung über die Patentgemäßheit der (von ihr bestrittenen) Änderungen beantragt.

IV.

Aufgrund der wortsinngemäßen Verletzung des Anspruchs 5 des Klagepatents waren der Klägerin die Klageanträge im tenorierten Umfang zuzusprechen.

1. Der Verantwortlichkeit der Beklagten zu 1 und 4 für die begangene Patentverletzung sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Entgegen der Auffassung der Beklagten besteht jedoch auch eine Verantwortlichkeit der Beklagten zu 2 und 3.

   a) Unter einem patentverletzenden Anbieten ist eine im Inland begangene Handlung zu verstehen, die nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden

Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel). In Verkehr gebracht werden patentverletzende Erzeugnisse, wenn Dritten im Inland die Verfügungsgewalt verschafft wird. Als Teilnehmer an Benutzungshandlungen eines anderen haften Personen, die diese Benutzungshandlungen ermöglichen oder fördern. Ob die Beklagte zu 3 bereits durch eine von ihr geduldete Nennung im Impressum der Internetseite www.[...].com/de, die den inländischen Verkehrskreisen eine deutsche Gesellschaft als inländischen Ansprechpartner präsentiert oder sogar suggeriert und hierdurch den Absatz der Beklagten zu 1 fördern mag, für die Patentverletzung verantwortlich ist, kann dahinstehen. Unerheblich ist auch, dass die Beklagte zu 3 nach den Behauptungen der Beklagten an „konkreten" Vertriebshandlungen nicht beteiligt sein und keine vertraglichen Lieferbeziehungen zu Distributoren unterhalten mag, die Endgeräte der Beklagten zu 1 an gewerbliche Kunden und Endkunden vertreiben. Die Beklagte zu 3 ist nämlich nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin im als Anlage K 14 vorgelegten Jahresbericht für „marketing, repair and after-sales services" auf dem deutschen Markt zuständig und wurde zu diesen Zweck im Jahr 2010 gegründet. Dies untermauert, dass die Beklagte zu 3 an den Absatzbemühungen des [...]-Konzerns in Deutschland mitwirkt. Für eine vorwerfbare Beteiligung am Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte zu 3 selbst als Vertragspartner im Geschäftsverkehr auftritt und Verträge in eigenem Namen abschließt. Es genügt, wenn sie die Absatzgeschäfte auf andere Weise fördert. Dies kann auch durch Marketing-Maßnahmen, einen Reparaturservice oder durch die Erbringung Serviceleistungen an den bereits verkauften Geräten geschehen, zumal diese ohne Service-Netzwerk und Kundenbetreuung nur schwer abzusetzen sein dürften. Die Zuständigkeit für dieses im Jahresbericht der Konzernmutter nach dem unwidersprochenen Klägervortrag genannte Aufgabenfeld hat die Beklagte zu 3 jedenfalls nicht in erheblicher Weise in Abrede gestellt.

b) Nach dem nicht widersprochenen Vortrag der Klägerin fördert die Beklagte zu 2 über ihre Internetseite www.[...]partner.eu und durch Informationsveranstaltungen wie die „Partner Tour" den inländischen Absatz der Beklagten zu 1 mit den angegriffenen Ausführungsformen. Auch diese Förderung des Absatzes der Beklagten zu 1 begründet eine vorwerfbare Beteiligung der Beklagten zu 2 am Anbieten der angegriffenen Ausführungsformen im Inland durch die Beklagten zu 1.

2. Der zugesprochene Anspruch auf Rechnungslegung folgt aus § 140b PatG und § 242 BGB, der Schadensersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG und der Entschädigungsanspruch aus § 33 Abs. 1 PatG. Im Hinblick auf die Beklagten zu 2 und 3 rechtfertigt eine festgestellte Benutzungshandlung die Verurteilung wegen der weiteren tenorierten Handlungen, da diese nach der Ausrichtung der Unternehmen als möglich in Betracht kommen. Insbesondere ist es in Konzernverhältnissen ohne weiteres möglich, dass die Rollenverteilung der Konzerngesellschaften jederzeit geändert wird, etwa in dem nunmehr die eine Gesellschaft nicht mehr anbietet, sondern in den Verkehr bringt und umgekehrt. Die Beklagten trifft ab dem 05.02.2011, einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents, zumindest der Fahrlässigkeitsvorwurf, weshalb der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach begründet ist. Ebenso trifft die Beklagten ab 21.Oktober 2000, einen Monat nach Veröffentlichung der Hinweises nach § 32 Abs. 5 PatG, zumindest der für den Entschädigungsanspruch erforderliche Fahrlässigkeitsvorwurf. Die Klägerin kann derzeit den Umfang eventueller Schäden und der Entschädigung nicht darlegen, da sie die zur Berech-

nung erforderlichen Grundlagen erst durch Rechnungslegung erhalten wird, weshalb das notwendige Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO besteht. Auch insoweit kann offen bleiben, ob die angegriffenen Ausführungsformen mittlerweile derart abgewandelt wurden, dass sie die patentgemäßen Fähigkeiten nicht mehr aufweisen. Selbst wenn dem so wäre, ist auch ein künftiger Schaden durch die Patentverletzung mit den nicht abgewandelten Ausführungsformen nicht von vornherein ausgeschlossen, so dass die Feststellungsklage auch insoweit begründet ist.

3. Zu berücksichtigen ist allerdings noch, dass die Beklagte zu 3 nach dem Klägervortrag erst im Jahr 2010 gegründet wurde. Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Handelsregisterauszugs (Anlage K 15) fand die Gründung mit Gesellschaftsvertrag vom 15.07.2010 statt. Ab diesem Zeitpunkt bestand die Beklagte zu 2 als Vorgesellschaft und erhielt mit der späteren Registereintragung identitätswahrend die Rechtsform der GmbH. Auch im Zeitraum zwischen der Gründung und der Registereintragung bestand die Möglichkeit, dass die Beklagte zu 3 geschäftlich tätig geworden sein könnte. Hieraus ergibt sich die aus dem Tenor ersichtliche Beschränkung ihrer Auskunft- und Entschädigungspflichten auf den Zeitraum ab dem 15.07.2010 als dem Zeitpunkt ihrer Gründung.

5. Der Geltendmachung der Rechte aus dem Klagepatent steht nicht der Einwand des Doppelschutzverbots gem. Art. II § 8 IntPatÜG entgegen.

   a) Der Wirkungsverlust tritt nach Art. II § 8 IntPatÜG – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – ein, soweit das deutsche Patent dieselbe Erfindung wie das europäische schützt. Es hat mithin ein Vergleich der Schutzbereiche zu erfolgen, wobei das Doppelschutzverbot nur gleichwertigen Schutz beseitigen möchte. Gibt das deutsche Patent dem Inhaber potentielle Vorteile bei der Rechtsdurchsetzung, die ihm das europäische Patent nicht gewährt, greift das Doppelschutzverbot nicht (vgl. *Rinken/Kühnen* in Schulte, PatG, 9. Aufl., § 9 PatG Rn. 109). Diskutiert wurden vor allem Fallkonstellationen, in denen das europäische Patent einen engeren wortsinngemäßen Schutzbereich hatte (vgl. etwa *Kühnen*, FS König, S. 309 ff.). Weiter wird vertreten, dass ein solcher Vergleich der Schutzbereiche abstrakt wenig sinnvoll sei, sondern nur in Bezug auf den Verletzungsgegenstand sinnvoll erfolgen könne (vgl. *Keukenschrijver* in Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., Art. II § 8 IntPatÜG, Rn. 3; LG Düsseldorf, GRUR 1993, 812). Weist das deutsche Patent gegenüber dem europäischen Patent einen Überschuss auf, wird dieser Überschuss nicht erfasst, sondern bleibt grundsätzlich wie im Nichtigkeitsverfahren bei beantragter Teilvernichtung als Schutzrecht bestehen (vgl. *Rinken/Kühnen* in Schulte, PatG, 9. Aufl., § 9 PatG Rn. 109).

   b) Für den Wirkungsverlust trägt nach allgemeinen Regeln die Beklagtenseite die Darlegungs- und Beweislast. Insbesondere muss sie – jedenfalls dann, wenn die Klägerin wie hier dies in Abrede stellt – substantiiert zum Schutzbereich des in Frage stehenden europäischen Patents vortragen. Dies haben die Beklagten vorliegend nicht getan. Sie haben sich im Wesentlichen auf eine Gegenüberstellung von Merkmalen und die Darlegung, weshalb auch Anspruch 5 eine „Umfassungsprüfung" implizit enthalten soll, beschränkt. Eine konkrete Erläuterung des Sinngehalts der einzelnen Merkmale des herangezogenen europäischen Patentanspruchs erfolgt nicht.

   c) Abgesehen davon geht Anspruch 5 des Klagepatents jedenfalls insoweit über Anspruch des EP 1 186 189 hinaus, als er zusätzliche spezielle Merkmale aufweist. Selbst wenn die übrigen Merkmale der beiden Patente deckungsgleich sein sollten, läge mithin die Si-

tuation eines abhängigen Patents vor. In einer solchen Konstellation erscheint es nicht gerechtfertigt, dem deutschen Patent die Wirkung zu nehmen. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass das allgemeinere europäische Patent nicht bestandskräftig ist und auch nicht auf das deutsche Patent eingeschränkt werden kann, so dass das deutsche Patent einen potentiell besseren Schutz als das europäische bietet.

6. Die gerichtliche Durchsetzung der Schadensersatz- bzw. Entschädigungspflichtfeststellung und der sie vorbereitenden Rechnungslegungsansprüche verstößt nicht gegen kartellrechtliche Pflichten, so dass offen bleiben kann, ob der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommt. Die gerichtliche Geltendmachung der genannten Ansprüche hat nämlich keine unmittelbare Auswirkung darauf, ob die Produkte der Beklagten auf den Markt gelangen oder auf ihm verbleiben, und ist daher kartellrechtlich nicht relevant (EuGH, Urt. v. 16.07.2015, Az. C-170/13, Rn. 72 ff. - juris, „Huawei ./.ZTE"). An dieser Bewertung ändert sich auch nichts, wenn der Schadensersatzfeststellungsanspruch auch in die Zukunft gerichtet ist. Dass der Europäische Gerichtshof die Feststellung in die Zukunft gerichteter Schadensersatzansprüche für kartellrechtlich problematisch ansehen würde oder gar aus kartellrechtlichen Gründen beschränken wollte, lässt sich dem Urteil vom 16.07.2015 nicht entnehmen. Eine solche Einschränkung ist auch nicht angezeigt, da der lizenzwillige Patentbenutzer in der Zukunft ohnehin Lizenzzahlungen zahlen müsste. Dass für eine Patentbenutzung geschuldete Zahlungen den Patentbenutzer vom Marktzutritt oder Marktverbleib abhalten könnten, ist kartellrechtlich unproblematisch.

   Soweit die Beklagten die Auffassung vertreten, dass dann, wenn dem Inhaber eines standardessentiellen Patents eine marktbeherrschende Stellung zukommt und er eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat, der Schadensersatzanspruch insoweit auf FRAND-Lizenzgebühren zu beschränken und auch nur beschränkt Auskunft zu erteilen ist, steht dies ebenfalls nicht im Einklang mit der Entscheidung „Huawei ./. ZTE", in der der Gerichtshof gerade klargestellt hat, dass der Schadensersatzanspruch und der Rechnungslegungsanspruch durch die in dieser Entscheidung beleuchteten kartellrechtlichen Aspekte nicht berührt werden.

   Abgesehen davon wäre die Frage, nach welchen Grundsätzen ein Schadensersatzanspruch zu berechnen ist, ohnehin erst im Betragsverfahren zu klären. Die Feststellung der Ersatzpflicht für „allen Schaden" enthält insoweit keine Vorfestlegung. Sie bedeutet nicht, dass jeglicher nur erdenkliche Schaden unabhängig davon, was rechtlich als Schaden anzusehen wäre, zu ersetzen ist. Die Feststellung lässt es daher offen, nach welchen Grundsätzen der zu ersetzende „alle Schaden" zu berechnen ist. Auch wenn man der Ansicht sein wollte, dass der zu ersetzende Schaden von vornherein nur im Wege der Lizenzanalogie mit FRAND-Lizenzgebühren zu berechnen sei, stünde dies der tenorierten Feststellung mithin nicht entgegen. Gleiches gilt für den Umfang des zugesprochenen Rechnungslegungsanspruchs. Die Beklagten wenden sich gegen eine Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht hinsichtlich der einzelnen Angebote und der betriebenen Werbung. Selbst im Fall der Beschränkung des Schadensersatzanspruches auf eine FRAND-Lizenzgebühr, würde die Auskunftspflicht jedoch auch diese Informationen umfassen, da sie jedenfalls zweckdienlich sind, um die vom Patentbenutzer gemachten Angaben zu plausibilisieren. Anhand der einzelnen Angebote und Angebotsempfänger kann der Patentinhaber jedenfalls grob überprüfen, ob die gemeldeten Lieferungen vollständig sind. Vor dem Hintergrund der betriebenen Werbung kann er ggf. einschätzen, ob die Absatzzahlen realistisch sind. Darauf, ob die ein-

zelnen Angebote und die betriebene Werbung unmittelbare Rechengrößen für die Festlegung des Schadensersatzes sind, kommt es für den Umfang der Auskunftspflicht nicht an.

V.

Der Rechtsstreit war nicht bis zur Entscheidung über die gegen die das Klagepatent im geltend gemachten Umfang aufrechterhaltende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtete Beschwerde auszusetzen. Die Entscheidung über die Beschwerde ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

   a) Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von den Beklagten glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Rechte für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende (d.h. überwiegende) Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 - Kurznachrichten; Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 107).

   b) Ist das Klagepatent im Einspruchsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren erstinstanzlich aufrechterhalten worden und erscheint diese Entscheidung mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar, besteht regelmäßig kein Anlass für eine Aussetzung. Ein solcher Anlass besteht regelmäßig indes etwa dann, wenn die das Klagepatent aufrechterhaltende Entscheidung offensichtlich unrichtig ist oder neuer Stand der Technik präsentiert wurde, der ohne sich einem Nachlässigkeitsvorwurf auszusetzen, erstinstanzlich noch nicht vorgelegt wurde (vgl. *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1859).

   c) An diesen grundsätzlichen Maßstäben ändert sich nichts dadurch, dass die Klägerin vorliegend nur noch den Anspruch auf Rechnungslegung und die Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht verfolgt. Bei der Frage der Aussetzung sind alle Interessen der Beteiligten gegeneinander abzuwägen. Auf der einen Seite steht das Interesse des Patentinhabers, dem das Patent nur einen zeitlich begrenzten Schutz gewährt, möglichst zügig die Rechte aus seinem Schutzrecht durchzusetzen. Eine Aussetzung würde insoweit zu einer faktischen Suspendierung des nur zeitlich begrenzten Patentschutzes für einen nicht unerheblichen Zeitraum führen. Auf der anderen Seite steht das Interesse der Beklagtenseite, nicht auf der Grundlage eines Klagepatents, das sich später als nicht rechtsbeständig erweist bzw. widerrufen wird, verurteilt und insbesondere am Marktzugang gehindert zu werden. Weiter ist auch zu berücksichtigen, dass auch ein allgemeines Interesse besteht, sich widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Zwar sind die Interessen einer Klagepartei, die nur noch Rechnungslegung und Schadenersatz bzw. Entschädigung begehrt, weniger gewichtig, denn diese Rechte werden durch den Zeitablauf nicht in vergleichbarer Weise wie die patentrechtlichen Verbietungsrechte entwertet. Es besteht aber gleichwohl noch ein Interesse an zeitnahem Rechtsschutz, insbesondere an der zeitnahen Auskunft/Rechnungslegung, um etwa gegen wei-

tere Verletzer vorgehen zu können. Auf der anderen Seite verlieren zudem auch die Interessen der Beklagtenpartei in diesem Fall an Gewicht. Eine Behinderung des Marktzugangs durch den Unterlassungsanspruch oder die Ansprüche auf Vernichtung oder Rückruf ist nicht mehr zu besorgen. Die bloße Feststellung der Entschädigungs- bzw. Schadensersatzpflicht belastet die Beklagtenpartei zunächst nicht unmittelbar. Sie hat allenfalls mittelbare Folgen, wie etwa bei der Frage, ob bilanzrechtlich Rückstellungen zu bilden sind. Eine Auskunftserteilung/Rechnungslegung führt zwar zu Belastungen der Beklagten in Form des Aufwands für die Auskunftserteilung. Auch offenbart sie ansonsten geheim gehaltene Informationen, auch wenn diese nur zweckgebunden verwendet werden dürfen. Auch können durch die Offenlegung einmal entstandene Nachteile nicht oder nur schwer ausgeglichen werden. Allerdings erreichen diese Aspekte im vorliegenden Fall nicht das Gewicht, um eine Aussetzung zu rechtfertigen.

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen, da kein neuer Stand der Technik in Rede steht, der der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht vorlegen hätte, und die Beklagten nicht dargetan haben, dass die Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts offensichtlich unrichtig ist.

   a) Einwände gegen die Neuheit des Anspruchs 5 in seiner vom Deutschen Patent- und Markenamt aufrechterhaltenen, hier geltend gemachten Fassung haben die Beklagten nicht vorgebracht. Jedenfalls haben sie gegen die Auffassung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, wonach Neuheit gegeben sei, nichts Erhebliches vorgetragen. Auch gegen die Auffassung der Patentabteilung, dass keine unzulässige Erweiterung vorliege, haben die Beklagten nichts Erhebliches vorgebracht. Sie berufen sich in Abweichung vom Deutschen Patent- und Markenamt lediglich auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit.

   b) Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat als erfinderisch angesehen, dass Teilnehmerstationen, die einer Nutzerklasse angehören, für die das zugehörige Zugriffsbit 0 ist, unabhängig vom Zugriffsschwellwert auf den Telekommunikationskanal zugreifen können (vgl. Anlage K 54 sub 2 c, sub 2 c aa, sub 2 c bb (1) und (2)). Die Verwendung der Zugriffsbits in Anspruch 5 sei die Umkehrung der bisher bekannten Verwendung eines Zugriffsbits, die darin gelegen habe, anhand des Zugriffsbits darüber zu entscheiden, ob ein sofortiger Zugriff gewährt oder unmittelbar verwehrt wird (sub 2 c bb (1)). Demnach ist es nach Auffassung der Patentabteilung erfinderisch, in Abhängigkeit des Zugriffsbits (0 oder 1) zu entscheiden, ob der Zugriff ohne weiteres oder nur in Abhängigkeit vom Ergebnis eines Zugriffsschwellenwertvergleichs gewährt wird.

   c) Die Kammer verkennt nicht, dass – entgegen der Auffassung der Klägerin – der Bundesgerichtshof die Frage, ob es erfinderisch ist, in Abhängigkeit vom Wert des Zugriffsbits entweder einen sofortigen Zugriff unabhängig vom Zugriffsschwellenwert oder einen Zugriff nur in Abhängigkeit von Zugriffsschwellenwerttests zuzulassen, anders als das Deutschen Patent- und Markenamt beurteilt haben könnte.

      aa) Der Bundesgerichtshof hat den deutschen Teil des EP 1 186 189 (im Folgenden „Streitpatent BGH") mit Urteil vom 14.10.2014 für nichtig erklärt (Anlage [B] 7). Der primär verteidigte Verfahrensanspruch 1 lautet in einer gegliederten Fassung wie folgt:

1.1 Das Verfahren dient der Vergabe von Zugriffsrechten auf mindestens einen, von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes an mindestens eine Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) des Telekommunikationsnetzes.

1.2 Hierzu werden Informationssignale an die Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) übertragen.

1.3 Die Informationssignale enthalten Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55).

1.4 In einer Auswerteeinheit (60) der Teilnehmerstation (5, 10,15, 20) wird geprüft, ob die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) umfassen.

1.5 Der Zugriffsschwellwert (S) wird mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) verglichen.

1.6 Das Zugriffsrecht der Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) auf einen Telekommunikationskanal wird in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis zugeteilt.

1.7 In der Auswerteeinheit wird geprüft, ob die Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) Zugriffsberechtigungsinformationen (S0, S1, S2, S3, S4, Z0, Z1, Z2, Z3) mit Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) für mindestens eine vorgegebene Nutzerklasse (35, 40) umfassen.

1.8 In diesem Fall und unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) einer vorgegebenen Nutzerklasse (35, 40) zugeordnet ist, wird der Zugriff auf mindestens einen Telekommunikationskanal in Abhängigkeit von den Zugriffsklasseninformationen (ZO, Z1, Z2, Z3) für diese Nutzerklasse (35, 40) erteilt.

bb) Eine Übertragbarkeit der Entscheidung auf den hiesigen Fall ist nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass der Bundesgerichtshof in Rn. 91 f. seines Urteils ausgeführt hat, dass das Urteil den Entscheidungen der britischen Gerichte, der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 11.02.2014 betreffend das Patent EP 1 841 268 sowie dem Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 06.03.2013 betreffend das Klagepatent nicht entgegenstehe, weil der Gegenstand jener Patente vom Gegenstand des vom Bundesgerichtshof beurteilten Anspruchs abweiche. Diese Ausführungen betreffen nämlich nur den ursprünglichen Patentanspruch des dort streitgegenständlichen Patents. Die Unterschiede zwischen den Patenten sieht der Bundesgerichtshof darin, dass die in jenen Verfahren zu beurteilenden Patente – also auch das hiesige Klagepatent – in Konkretisierung des Merkmals 1.8 des Anspruchs 1 des vom Bundesgerichtshof beurteilten Patents vorsähen, dass die Informationen über die Zugriffsklassen als Kriterium dafür herangezogen werden, ob eine Mobilstation ohne weiteres Zugriff erhält oder ob sie sich zusätzlich einer Überprüfung anhand des Zugriffsschwellenwerts unterziehen muss; diese Einschränkung sei in dem beurteilten Anspruch 1 des Streitpatents des Nichtigkeitsverfahrens nicht enthalten (Rn. 92.)

cc) Neben dem Anspruch 1 hatte der Bundesgerichtshof indes u.a. den Hilfsverfahrensanspruch 1 und den Hilfsanspruch 3, der Teilnehmerstationen betrifft, des dortigen Streitpatents zu beurteilen.

In Hilfsanspruch 1 wurde das oben genannte Merkmal 1.8 dahingehend ergänzt, dass der Zugriff in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformationen und unabhängig vom Zugriffsschwellenwert erteilt wird, sofern die empfangenen Zugriffsberechti-

gungsdaten Zugriffsklasseninformationen für mindestens eine Nutzerklasse enthalten und die Mobilstation dieser Nutzerklasse angehört. Diesen Hilfsanspruch hat der Bundesgerichtshof als im Stand der Technik nahegelegt angesehen (Rn. 96 ff.). Hierbei stützte sich der Bundesgerichtshof auf die Entgegenhaltungen K 4 (GSM 04.60 V6.2.0 – im Prioritätszeitpunkt aktuelle Version des Standards, hier Anlage [B] 11), K 20 (GSM 04.60 V6.1.0 – frühere Fassung, hier Anlage [B] 12) und K 16 (Standard IS-95-A, hier Anlage [B] 13). Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes waren in den Dokumenten K 4 und K 20 grundlegende Methoden offenbart, um die Erteilung von Zugriffsrechten je nach Situation von unterschiedlichen Kriterien abhängig zu machen, wobei es zu diesen Methoden aus K 20 gehört habe, für bestimmte Datenpakete den Zugriff aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Prioritätsklasse und unabhängig von einem Schwellenwertvergleich zu ermöglichen (Rn. 104). Auf dieser Grundlage und angesichts der Ähnlichkeit zwischen einer Priorisierung von Datenpaketen und der von Nutzerklassen hat er es als dem Fachmann nahegelegt angesehen, diese Methode auch zur Priorisierung von Nutzerdaten heranzuziehen und die Erteilung des Zugriffs bei Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse nicht zusätzlich vom Ergebnis eines Schwellwertvergleichs abhängig zu machen.

Hilfsanspruch 3, der Teilnehmerstationen zum Gegenstand hat, hat der Bundesgerichtshof ebenfalls nicht als erfinderisch angesehen. Hilfsanspruch 3 hat der Bundesgerichtshof so ausgelegt, dass die Auswerteeinheit anhand der Zugriffsklasseninformation überprüft, ob der Teilnehmerstation der Zugriff unabhängig vom Zugriffsschwellenwert erteilt wird oder ob die Zugriffsberechtigung über die Ermittlung des Schwellenwertvergleichs ermittelt werden muss (Rn. 115). Er hat Hilfsanspruch 3 lediglich als Konkretisierung des Hilfsanspruch 1 angesehen und konsequent unter Verweis auf die Erwägungen zum Hilfsanspruch 1 als ebenfalls nicht erfinderisch verworfen (vgl. [B] 7, Rn. 116).

Die Klägerin meint, der Bundesgerichtshof habe das Merkmal der Zugriffserteilung „in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformation für diese Zugriffsklasse und unabhängig von dem Zugriffsschwellenwert" aus dem verworfenen Hilfsanspruch 1 dahingehend aufgefasst, dass die Zugriffsklasseninformation in die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffsrechts einfließen müsse, sofern Zugriffsklasseninformationen für die jeweilige Nutzerklasse vorhanden seien, und nach dem Bundesgerichtshof liege ein zugriffsschwellenwertunabhängiger Zugriff dann vor, wenn gar kein Zugriffsschwellenwert gesendet werde. Dies weiche erheblich von der Lehre des Anspruchs 5 des Klagepatents ab, wonach die Zugriffsklasseninformation das Kriterium darstelle, ob direkt zugegriffen werden darf oder ob ein zusätzlicher Zugriffsschwellentest durchzuführen ist. Da der Bundesgerichtshof keinen Unterschied zwischen Hilfsanspruch 1 und 3 sehe, könne auch Hilfsanspruch 3 anders als Anspruch 5 des Klagepatents nicht die Zugriffsklasseninformation als das Kriterium für die Entscheidung zwischen einer direkten Zugriffsgewährung und einer Zugriffsgewährung in Abhängigkeit vom Zugriffsschwellentest ansehen.

Die Zusammenschau der Rn. 103, 104, 115 bis 117 der Entscheidung des Bundesgerichtshofs spricht indes eher dafür, dass der Bundesgerichtshof die Verwendung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten, in der Zugriffsklasseninformation als bevorrechtigt ausgewiesenen Nutzerklasse im Rahmen einer Zugriffsverwaltung als Krite-

rium dafür, ob ein unmittelbarer Zugriff gewährt wird oder aber der Zugriff vom Ergebnis eines Schwellwertvergleichs abhängt, als im Stand der Technik nahegelegt ansieht. Bereits in Rn. 103 stellt der Bundesgerichtshof in Bezug auf den Hilfsanspruch 1 fest, dass die Entgegenhaltung K 4 dem Fachmann hinreichende Veranlassung gegeben habe, das dort offenbarte Verfahren dahin weiterzuentwickeln, „dass die Erteilung des Zugriffs bei Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse nicht zusätzlich vom Ergebnis eines Schwellenwertvergleichs abhängt". Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse scheint damit das Kriterium zu sein, ob die Mobilstation direkten Zugriff erhält oder sich einem Zugriffsschwellentest unterziehen muss. Bei der Erörterung des Hilfsanspruchs 3 benennt der Bundesgerichtshof in Rn. 115 sogar ausdrücklich die Zugriffsklasseninformation als das entscheidende, durch die Mobilstation zu prüfende Kriterium, anhand dessen nach Hilfsanspruch 3 über die Alternativen direkter Zugriff oder Ermittlung der Zugriffsberechtigung über die Durchführung des Schwellwertvergleichs entschieden wird.

Kein Zweifel dürfte jedenfalls bestehen, dass der Bundesgerichtshof bei seiner Entscheidung, den Hilfsanspruch 3 zu verwerfen, zugrunde gelegt hat, dass es dort die Mobilstation ist, die anhand der Zugriffsklasseninformation prüft, welcher Weg für den Zugriff (direkter Zugriff oder Durchführung des Zugriffsschwellenvergleichsverfahren) beschritten wird (vgl. [B] 7 Rn. 115). Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Bundesgerichtshof mit einem zugriffsschwellenwertunabhängiger Zugriff lediglich meine, dass gar kein Zugriffsschwellenwert gesendet werde.

Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich aus dem Umstand, dass sich der Bundesgerichtshof bei der Erörterung des Hilfsanspruchs 3 nicht mit den abweichenden Judikaten auseinandersetzt, nicht folgern, dass er bei Hilfsanspruch 3 (entgegen seinem Wortlaut, vgl. [B] 8) die Zugriffsklasseninformation nicht als das entscheidende Kriterium für die Entscheidung, ob ein direkter Zugriff erfolgt oder ein Zugriffsschwellenwerttest erfolgt, angesehen hat. Denn der Bundesgerichtshof hat sich mit den abweichenden Judikaten unter diesem Gesichtspunkt bereits im Rahmen der Erörterung des Hilfsanspruchs 1 befasst. Insoweit hatte er ausgeführt, dass die britischen Gerichte lediglich die Entgegenhaltung K 4, nicht aber die Entgegenhaltung K 20 für ihre Argumentation herangezogen hätten. Der Klägerin ist jedoch zuzugeben, dass er sich an dieser Stelle nicht mit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts auseinandergesetzt hat. Dies ändert aber nichts daran, dass der Wortlaut der Rn. 115 dafür streitet, dass der Bundesgerichtshof auch die Wahl der Zugriffsklasseninformation als das entscheidende Kriterium für die Entscheidung, ob ein direkter Zugriff erfolgt oder sich die Mobilstation einem Zugriffsschwellenwerttest unterziehen muss, und die Prüfung dieses Kriteriums durch die Mobilstation als im Stand der Technik nahegelegt angesehen hat.

d) Es spricht zudem einiges dafür, dass die Merkmale des Anspruchs 5 des Klagepatents, die vom verworfenen Hilfsanspruch 3 im Streitpatent aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichen, nämlich das Feststellen der Zugehörigkeit zu einer Nutzerklasse anhand der Zugangsberechtigungskarte (Merkmal 3), die Ausführung der Zugriffsberechtigungsdaten als Bitmuster (Merkmal 5 erster Spiegelstrich), die Ausführung von Zugriffsklasseninformationen in Gestalt von Zugriffsklassenbits (Merkmal 5 zweiter Spiegelstrich) und die Ausführung von Zugriffsschwellenwerten in Gestalt von Zugriffschwellenwertbits (Merkmal 5 zweiter Spiegelstrich), nicht zu einer anderen Beurteilung des Anspruchs 5

des Klagepatents führen würden, wenn man davon ausgeht, dass die Prüfung anhand des Zugriffsklassenbits, ob ein unmittelbarer Zugriff oder nur ein Zugriff in Abhängigkeit von einem Schwellenwertvergleich gewährt wird, nicht erfinderisch ist. Die Ausführung der Zugriffsberechtigungsdaten als Bitmuster und die Speicherung der Zugehörigkeit zu einer der Nutzergruppen auf einer Zugangsberechtigungskarte einer Teilnehmerstation hat die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts bereits als im Stand der Technik nahegelegt angesehen (Anlage K 54, sub c aa). Auch dass die Zugriffsberechtigungsdaten Zugriffsklassenbits und Persistenzschwellenbits enthalten, ist nach Auffassung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts im Stand der Technik nahegelegt (Anlage K 54, sub c bb (1)). Es dürfte auch unwahrscheinlich sein, dass es für die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im genannten Nichtigkeitsverfahren maßgeblich gewesen wäre, wenn der Hilfsanspruch 3 statt auf Zugriffsklasseninformationen und Zugriffsschwellenwerte auf Zugriffsklassenbits und Zugriffschwellenwertbits abgestellt und auch die weiteren Merkmale 3 und 5 erster Spiegelstrich enthalten hätte.

e) Die vom Bundesgerichtshof gewürdigten Druckschriften lagen auch der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamt bei ihrer Entscheidung vor. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig und ergibt sich zudem aus der Auflistung in der Entscheidung der Patentabteilung. Damit ist nicht die Konstellation gegeben, dass neuer Stand der Technik vorliegen würde, der über den Stand der Technik hinausgeht, den die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts gewürdigt hat.

f) Mithin lassen sich gute Argumente dafür anführen, dass es der Bundesgerichtshof als im Stand der Technik nahegelegt angesehen hat, dass die Auswerteeinheit anhand der Zugriffsklasseninformation überprüft, ob der Teilnehmerstation der Zugriff unabhängig vom Zugriffsschwellenwert erteilt wird oder ob die Zugriffsberechtigung über die Ermittlung des Schwellenwertvergleichs ermittelt werden muss, während es die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts als erfinderisch angesehen hat, in Abhängigkeit des Zugriffsbits (0 oder 1) zu entscheiden, ob der Zugriff ohne weiteres oder nur in Abhängigkeit vom Ergebnis eines Zugriffsschwellenwertvergleichs gewährt wird, und dass die Konkretisierung der Zugriffsschwellenwerte bzw. der Zugriffsklasseninformation auf Zugriffsbits und Zugriffsschwellenwertbits keinen Unterschied machen kann. Da der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und dem Bundesgerichtshof der gleiche Stand der Technik zur Verfügung stand, lägen daher in diesem Punkt divergierende Auffassungen des Bundesgerichtshofs und der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vor. Auch wenn die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein anderes Patent betrifft, kommt ihr im Rahmen der bei der Aussetzungsentscheidung zu treffenden Abwägung Bedeutung zu, denn sie befasst sich mit der Frage, was aufgrund des Standes der Technik für die Ausgestaltung der Zugriffsverwaltung nahegelegen hat. Diese Frage ist zunächst einmal patentunabhängig.

Letztlich kann die Frage, ob eine von der Prüfabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts abweichende Bewertung des Bundesgerichtshofs vorliegt, jedoch dahinstehen, denn die Beklagten haben nicht aufgezeigt, dass die Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts offensichtlich unrichtig ist. Hierzu genügt allein der Verweis auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs für ein anderes Patent nicht. Vielmehr bedarf es substantiierten Vortrags anhand der vom Bundesgerichtshof erörterten Entgegenhaltungen, der zum einen aufzeigt, weshalb es offensichtlich ist, dass der Stand der Technik den Anspruch 5 des Klagepatents nahelegt und die Auffassung der

Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts unvertretbar ist, und zum anderen die Kammer in die Lage versetzt, diese Frage auch ohne sachverständige Hilfe zu beurteilen. Hierzu kann es ausreichen aufzuzeigen, dass dem Bundesgerichtshof dieselben Sachargumente vorlagen wie der Prüfabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und dort – ggf. mit Hilfe eines Sachverständigen – bewertet wurden. Einen solchen Vortrag haben die Beklagten weder mit Blick auf eine isolierte Offensichtlichkeit der Unrichtigkeit der Entscheidung der Prüfabteilung noch mit Blick auf eine offensichtliche Unrichtigkeit vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs gehalten.

aa) Geht man davon aus, dass der Bundesgerichtshof zu einer anderen Bewertung als die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts gelangt ist, würde dies – soweit ersichtlich – auf einer anderen tatrichterlichen Bewertung des Sachverhalts, nicht auf der Anlegung anderer rechtlicher Maßstäbe beruhen. Naturgemäß kann sich die offensichtliche Unrichtigkeit einer Entscheidung der Prüfabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts aus abweichenden Feststellungen des Bundesgerichtshofs in einem anderen Verfahren ergeben, wenn Gegenstand der Feststellungen ein vergleichbarer Gesichtspunkt ist, auch wenn in einem Beschwerdeverfahren eine rechtliche Bindung des Bundespatentgerichts an die tatrichterlichen Feststellungen des Bundesgerichtshofs aus einem Nichtigkeitsverfahren, das ein anderes Patent zum Gegenstand hat, nicht besteht. Die tatrichterliche Bewertung ist indes auch abhängig von den Sachargumenten, die die Verfahrensbeteiligten vorbringen. Eine Übertragung einer tatrichterlichen Bewertung setzt daher jedenfalls voraus, dass die zur Beurteilung stehenden Sachargumente in beiden Verfahren deckungsgleich sind.

bb) Einer Auseinandersetzung mit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts anhand der Entgegenhaltungen und einer Darlegung, dass dem Bundesgerichtshof und der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts dieselben Sachargumente vorlagen, bedarf es auch deshalb, weil die Klägerin Argumente ins Feld geführt hat, die nicht von vornherein als abwegig angesehen werden können. Insbesondere hat die Klägerin eingewandt, dass bei der patentgemäßen Lehre das Zugriffsklassenbit, das im Stand der Technik ein Instrument der unmittelbaren Zugriffsverwehrung gewesen sei, nach der patentgemäßen Lehre für eine reine Zugriffsgewährung ohne die Möglichkeit, eine unmittelbare und sichere Zugriffsverwehrung herbeizuführen, eingesetzt und damit zweckentfremdet werde. Eine sichere Zugriffsverwehrung kann nicht mehr mit Hilfe des Zugriffsklassenbits realisiert werden, weil die Zugriffsverwehrung bei der patentgemäßen Verwendung des Zugriffsklassenbits vom Ausgang des Schwellenwertvergleichs abhängt.

cc) Die Beklagten haben demgegenüber nicht aufgezeigt, dass die Argumentation mit der Zweckentfremdung des Zugriffsklassenbits auch Gegenstand der Erörterungen vor dem Bundesgerichtshof war. Ferner haben sie nicht anhand der Entgegenhaltungen aufgezeigt, dass die Bewertung des Bundesgerichtshofs auch vor dem Hintergrund des in der Entscheidung nicht – zumindest nicht explizit – behandelten Arguments über die Zweckentfremdung des Zugriffsklassenbits zwingend ist und nicht ggf. auf einer anderen Entscheidungsgrundlage beruht.

Soweit sie noch vor der Abtrennung des hiesigen Verfahrens aus dem Ursprungsverfahren mit Schriftsatz vom 17.02.2012, dort unter Teil B, Seiten 18 ff., zu dem Standard GSM 04.60 V6.2.0 (Entgegenhaltung K 20 aus dem Nichtigkeitsverfahren

zum EP 1 186 189) und der dortigen Paketdatenzugriffsverwaltung vorgetragen haben, lässt sich diesem Vortrag keine für die Kammer mit der notwendigen Sicherheit festzustellende Offensichtlichkeit entnehmen.

Nach den Ausführungen der Beklagten sei in der Zugriffsverwaltung für Paketdienstdaten vorgesehen gewesen, dass dann, wenn der entsprechende Bitwert für einen Paketdienst auf 1 gesetzt sei, der Zugriff verwehrt werde, bei einem Wert „0" werde er in Abhängigkeit vom Zugriffsschwellenvergleichstest ausgeführt. Der Bitwert entscheidet mithin über eine Zugriffsgewährung – ggfs. in Abhängigkeit von weiteren Prüfungen – oder einer sofortigen Zugriffsverwehrung. Es sei naheliegend – jedenfalls in Zusammenschau mit dem Dokument [B]-B 15 – diese Zugriffsverwaltung auf Nutzerklassen zu übertragen und dahingehend abzuwandelnd, dass statt der Alternative Zugriffsverwehrung die Alternative unmittelbare Zugriffsgewährung (d.h. ohne die Durchführung eines Vergleichstests) vorgesehen wird.

Die Beklagten führen weiter aus, dass nach der Teilspezifikation GSM 02.1, dort Abschnitt 4.1, der Zweck der Zugriffsklassensteuerung sei zu verhindern, dass bestimmte Mobilfunkteilnehmer Zugriffsversuche machen, um eine Überlastung des Zugriffskanals zu verhindern. Dies stützt die Argumentation der Klägerin und der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, dass beim patentgemäßen Vorgehen die Zugriffsklassenbits sozusagen zweckentfremdet werden, weil sie für das genaue Gegenteil des ursprünglichen Zwecks der unmittelbaren Zugriffsverwehrung, nämlich für eine unmittelbare Zugriffsgewährung, eingesetzt werden. Für eine Sperrung des Zugriffs zur Überlastungsvermeidung beim Zugriffskanal können sie bei der patentgemäßen Lehre nicht mehr ohne weiteres eingesetzt werden, weil die Zugriffssperrung von dem Vergleichstest abhängt. Mit diesem Argument hätten sich die Beklagten im Einzelnen auseinandersetzen müssen, um eine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zu begründen. Auch die Einspruchsschriften aus dem Einspruchsverfahren bringen nichts vor, was das Argument offensichtlich unvertretbar erscheinen lassen würde.

Eine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Prüfabteilung kann auch nicht deshalb als hinreichend sicher angenommen werden, weil die Prüfabteilung zwar die Entgegenhaltung aus Anlage K 4 aufgelistet, aber nicht explizit behandelt hat, denn die Prüfabteilung hat zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit gerade darauf abgehoben, dass die oben erläuterte Umkehrung des Zwecks der Zugriffskontrollklasse die Verneinung des Naheliegens begründe (vgl. Anlage K 54, 2 c bb (1)). Eine Übertragung dieses Arguments auf die oben dargestellte Paketdatenzugriffsverwaltung erscheint nicht fernliegend.

Auch mit Blick auf die weiteren von den Beklagten gegen die erfinderische Tätigkeit im Lauf des Verfahrens angeführten Entgegenhaltungen, die Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren, vermag die Kammer keine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts mit der notwendigen Sicherheit festzustellen.

Letztlich kann die Kammer eine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Prüfabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts daher auf der Grundlage der von den Parteien vorgebrachten Argumente nicht ohne sachverständige Hilfe beja-

hen. Hieran ändert auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im angesprochenen Nichtigkeitsverfahren nichts. Selbst wenn man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Sinne der Beklagten versteht, würde dies nicht dazu führen, dass die Kammer auch ohne sachverständige Hilfe von einer offensichtlichen Unrichtigkeit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts mit der notwendigen Sicherheit ausgehen könnte, da es sich um eine tatrichterliche Entscheidung handelt und die Beklagten nicht aufgezeigt haben, dass die zu bewertenden Sachargumente deckungsgleich sind, insbesondere das Argument der Zweckentfremdung des Zugriffsklassenbits bereits Gegenstand der – ggf. mit Hilfe eines Sachverständigen geführten – Erörterungen im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof war.

Kann die Kammer aufgrund der fehlenden eigenen Sachkunde eine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht annehmen, kommt eine Aussetzung grundsätzlich nicht in Betracht. Insbesondere ist es nicht angezeigt, zur Prognose der Erfolgsaussichten des Beschwerdeverfahrens einen Sachverständigen heranzuziehen. Eine solche Hinzuziehung wäre mit dem in Aussetzungsentscheidungen anzulegenden summarischen Prüfungsmaßstab, der lediglich eine Prognose und keine endgültige Entscheidung fordert, nicht zu vereinbaren.

Keine ausschlaggebende Bedeutung hat der Umstand, dass die Verhandlung vor dem Bundespatentgericht über das Klagepatent bereits im Zeitraum 11. bis 13. April 2016 stattfinden wird. Zwar ist es durchaus denkbar, dass ein relativ kurzer Zeitraum bis zu der Entscheidung im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren die Interessensgewichtung zugunsten der Beklagtenseite verschiebt. Vorliegend fehlt es jedoch aus den oben genannten Gründen an Vortrag, auf dessen Grundlage eine hinreichend sichere Prognose möglich wäre, dass das Klagepatent im Beschwerdeverfahren widerrufen werden wird.

VI.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1,100 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO bzw. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Der nicht nachgelassene Beklagtenschriftsatz vom 20.01.2016 bietet keine Veranlassung zur Wiederöffnung der mündlichen Verhandlung, § 296a ZPO. Soweit er weiteren Sachvortrag enthält, kam es bei der Entscheidung hierauf nicht an.

Voß	Dr. Tochtermann	Böttcher
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter